

<제9장 비정규근로자 제3절 파견근로자>

I. 의의

- 근로자파견이란 파견사업주가 근로자를 고용한 후, 그 고용 관계를 유지하면서 사용사업주에게 근로를 제공하게 하고, 사용사업주가 해당 근로자의 지휘·명령권을 행사하는 형태의 고용 관계를 의미한다. 이는 파견사업주, 사용사업주, 파견근로자의 삼자 관계로 이루어지며, 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')에 의해 규율된다.

II. 근로자파견과 도급의 구별

1. 의의

(1) 근로자파견

- 근로자파견은 근로자가 파견사업주와 근로계약을 맺고, 사용사업주의 사업장에서 사용사업주의 지휘·명령을 받아 근로를 제공하는 것이 본질이다.

(2) 도급

- 도급은 당사자 일방(수급인)이 어떤 일의 완성을 약정하고, 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다.(민법 제664조) 수급인이 자신의 책임과 자체적인 인사 관리에 따라 근로자를 지휘·명령하여 업무를 수행한다.

2. 구별

- 근로자파견과 도급은 법적 규제와 근로자의 고용 안정에 미치는 영향이 극히 달라 그 구별이 매우 중요하다.

(1) 지휘·명령권의 행사 주체

- 근로자파견의 경우, 근로자에 대한 실질적인 지휘·명령권은 사용사업주에게 있다. 도급의 경우, 근로자에 대한 지휘·명령권은 수급인(하청업체)에게 있다.

(2) 계약의 대상

- 파견계약은 노동력 제공 자체를 목적으로 한다. 도급계약은 일의 완성이라는 결과를 목적으로 한다.

3. 판단기준

- 대법원은 계약의 형식이 도급 또는 위탁으로 되어 있더라도, 그 실질이 근로자파견에 해당하는지 여부를 종속적 관계 유무를 기준으로 판단하며, 여러 요소를 종합적으로 고려한다.

(1) 업무 지시 및 통제

- ① 도급인이 작업 배치, 업무 지시, 근로 시간 결정 등 근로자에 대한 구체적이고 직접적인 지휘·감독을 하는지 여부. ② 작업 도구, 시설 등의 소유 관계 및 관리 책임이 어느 당사자에게 있는지 여부.

(2) 업무의 독립성 및 전문성

- ① 수급인이 업무 수행을 위한 독자적인 조직을 갖추고 있는지 여부. ② 업무 수행을 위해 도급인과 독립된 전문적인 기술이나 경영 노하우를 가지고 있는지 여부.

III. 근로자파견의 규제

- 파견법은 근로자파견의 남용을 막고 파견근로자의 근로조건을 보호하기 위해 사업의 허가 및 대상 업무와 기간에 엄격한 규제를 가한다.

1. 근로자파견사업의 허가[파견법 제7조 제1항, 제10조 제1항]

(1) 허가제 원칙

- 파견법 제7조 제1항은 근로자파견사업을 하려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 고용노동부령으로 정하는 중요사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.라고 규정한다.

(2) 유효기간

- 파견법 제10조 제1항은 근로자파견사업 허가의 유효기간은 3년으로 한다.라고 규정한다.

2. 근로자파견사업의 대상업무 및 파견기간

(1) 파견 대상 업무의 제한

- 파견법은 원칙적으로 근로자파견 대상 업무를 제한하며, 제외된 업무(금지 업무)에 대해서는 파견을 허용하지 않는다.

(2) 파견 기간의 제한

- 근로자파견의 기간은 1년을 초과할 수 없다. 다만, 당사자 간의 합의에 따라 1회에 한하여 추가로 1년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 즉, 총 파견 기간은 최대 2년을 초과할 수 없다.

IV. 직접고용의무[파견법 제6조의2]

- 파견법 제6조의2는 사용사업주가 파견법을 위반하여 근로자를 사용하는 경우, 해당 근로자를 보호하기 위해 사용사업주에게 직접 고용 의무를 부과한다.

1. 직접고용의무의 인정[파견법 제6조의2 제1항]

(1) 직접고용의무 발생 사유

- 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하는 경우는 다음과 같다. ① 파견 대상 업무가 아닌 업무에 근로자를 사용한 경우. ② 파견 기간 제한을 위반하여 2년을 초과하여 계속적으로 파견근로자를 사용한 경우. ③ 허가를 받지 아니한 파견사업주로부터 근로자를 파견받은 경우.

(2) 의무의 내용

- 사용사업주는 위반 사유가 발생한 시점에 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다.

2. 직접고용의무의 적용제외[파견법 제6조의2 제2항]

- 직접고용의무는 근로자 보호를 위한 규정이므로, 파견근로자가 다음의 사유에 해당하는 경우 직접고용의무가 적용되지 않는다. ① 파견근로자가 명시적으로 반대 의사를 표시하는 경우. ② 파견근로자가 합리적인 이유 없이 채용 제의에 응하지 아니한 경우.

3. 직접고용 시 근로조건[파견법 제6조의2 제3항]

(1) 근로조건 원칙

- 사용사업주가 파견근로자를 직접 고용하는 경우, 해당 근로자의 종전 근로조건보다 낮은 근로조건을 적용해서는 안 된다.

(2) 근로조건 결정

- 근로조건은 당사자 간의 합의에 따라 결정하되, 합의가 이루어지지 아니하는 경우에는 파견 전의 근로조건과 같은 수준 이상으로 정해야 한다.

4. 직접고용의무의 발생과 근로계약

(1) 법적 성격

- 직접고용의무는 강행규정으로서, 의무 발생 시점에 근로자에게는 사용사업주를 대상으로 고용 관계의 설정을 청구할 수 있는 권리가 발생한다.

(2) 계약의 형성

- 판례는 파견법상 직접고용의무의 발생은 근로자에게 청약 또는 청약의 승낙을 간주하는 효과가 발생하여, 사용사업주와 파견근로자 간에 직접 고용 계약이 성립되는 것으로 해석한다.

V. 결론

- 파견근로자 제도는 파견법에 의해 허가제, 대상 업무 및 기간 제한이라는 강력한 규제를 받는다. 위법한 파견이 발생하는 경우, 사용사업주에게 직접 고용의무가 부과되며, 이는 근로자의 명시적 거부 등 예외 사유가 없는 한 법률상 직접 고용 관계의 성립을 강제하는 효과를 가진다. 또한, 형식상 도급이라 하더라도 그 실질이 사용사업주의 지휘·명령에 따르는 파견에 해당하면 파견법이 적용되어 근로자를 보호한다.